

1502881-46.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... diligências pelo conhecido ponto de tráfico de entorpecente e que, mediante uso de equipamento fotográfico amador, registraram a movimentação de tráfico praticada pelos acusados. A conduta dos indivíduos se deu da seguinte forma: os acusados, algumas vezes, ficavam em frente a um bar, localizado do outro lado da rua, diante da entrada do estacionamento do CDHU, e, em outros ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502881-46.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2249141/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 20217521 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 113/21/557 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2249141 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2249141/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO PALMA NOGUEIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Cuida-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de LEONARDO PALMA NOGUEIRA e GUSTAVO PEREIRA DE SOUZA, já qualificados nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Consta da denúncia que, no dia 13 de setembro de 2021, por volta das 17h00, na Rua Júlia Lopes Pinheiro, nº 70, CDHU Padre Anchieta, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, os acusados, previamente conluiados e agindo com unidade de desígnios, cada um fazendo sua a ação alheia, traziam consigo e tinham em depósito, com intuito de entrega a consumo de terceiros, 45ml (quarenta e cinco mililitros) de Cloreto de Metileno/Diclorometano, popularmente conhecido como lança-perfume, divididos em 03 (três) frascos, 115,5g (cento e quinze gramas e cinco decigramas) de Tetrahydrocannabinol (THC), acondicionados em 18 (dezoito) porções individuais,

3,0g (três gramas) de cocaína, na forma de crack, divididos em 20 (vinte) porções individuais, 12,7g (doze gramas e sete decigramas) de cocaína, divididos em 33 (trinta e três) porções individuais, 0,4g (quatro decigramas) de cocaína, acondicionados em 01 (uma) porção individual, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Auto de prisão em flagrante (pág. 05); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 13/16); auto de exibição e apreensão (págs. 17/18); laudo de constatação preliminar (págs. 71/77) e definitivo (págs. 153/156).

Por decisão data de 15 de outubro de 2021 (págs. 186/187), foi determinada a notificação dos acusados, sendo que Leonardo Palma Nogueira apresentou defesa preliminar mediante advogado constituído (págs. 223/225) e Gustavo Pereira de Souza o fez igualmente mediante advogado constituído (págs. 259/269).

Não sendo o caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 11 de novembro de 2021 (págs. 280/283), e os réus foram devidamente citados (págs. 294/295 e 296), ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas e, após, foram os réus interrogados.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação nos exatos moldes da denúncia.

A defesa do acusado Leonardo pleiteou pela absolvição; No caso de condenação, requereu a aplicação do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa do réu Gustavo pleiteou pela absolvição; subsidiariamente, pleiteou pela desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Em caso de condenação, postulou pela fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação do §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos carreados aos autos, o pedido inicial é procedente.

A materialidade de delito encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de autoria conhecida, bem como pelo auto de exibição, apreensão e pelos laudos periciais.

Do mesmo modo, a autoria restou incontestada ante toda a prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e direito à ampla defesa.

Vejamos.

A testemunha Victória Luiza da Silva, em sede administrativa, narrou que havia deixado sua residência para residir com o acusado Leonardo em janeiro de 2021. Ademais, explicou que trabalha como operadora de telemarketing e foi fazer uma entrevista na data dos fatos para trabalhar na empresa Motiva, sendo a depoente, assim, provedora do lar, pois Leonardo trabalha de autônomo. Quanto aos fatos, narrou que, em sua data, tinha ciência de que ele estava usando cocaína pelo local dos fatos. Foi até lá com intenção de partilharem uma marmita, momento em que foi abordada junto dele e do acusado Gustavo, quem conhece apenas de vista. A depoente acrescentou que não estava traficando drogas, que não usa qualquer tipo de entorpecente, bem como que não possui antecedentes criminais e nem registro de ocorrência. Ademais, afirmou que não tinha ciência da conduta de Leonardo, pois, como mencionou, foi falar com ele após sua entrevista, não podendo participar de sua conduta.

Em juízo, disse que estava no local dos fatos no momento da prisão. Que Leonardo sempre foi usuário de drogas. No dia dos fatos, Leonardo foi ao local para comprar cocaína. Que um homem chegou e disse que se Leonardo guardasse uma "bolsinha" atrás de um veículo, ganharia três pinos de droga.

A testemunha Roberto Gurgueira Nogueira, policial civil, em sede administrativa, narrou que, na data dos fatos, presentes os policiais civis da equipe Lince 208, noticiando que realizaram diligências pelo conhecido ponto de tráfico de entorpecente e que, mediante uso de equipamento fotográfico amador, registraram a movimentação de tráfico praticada pelos acusados. A conduta dos indivíduos se deu da seguinte forma: os acusados, algumas vezes, ficavam em frente a um bar,

localizado do outro lado da rua, diante da entrada do estacionamento do CDHU, e, em outros momentos, no próprio estacionamento, esperando por clientes. Em tais situações, os acusados entregavam-lhes as porções de drogas solicitadas, as quais ficavam escondidas dentro de uma pochete, mantida sobre a roda traseira de um automóvel que permanecia estacionado. Ficou claro durante o tempo de observação que os acusados agiam juntos. A dupla não permanecia com a droga em seu poder, escondendo-a junto ao carro. O depoente explicou que essa conduta é rotineiramente observada nos pontos de tráfico, pois, em caso de abordagem policial, nada será encontrado diretamente no poder do traficante; esse, normalmente, não traz nada consigo, pegando de seu esconderijo apenas a quantidade solicitada por cada novo comprador. Retomando a narrativa dos fatos, o depoente explicou que, a cada nova venda a dupla seguia em direção ao esconderijo da droga, repetindo o gesto já descrito. Também foi vista pelo local a testemunha Victória, namorada de Leonardo, a qual, durante algum tempo, conversou com o acusado no momento em que ele se dedicava ao tráfico. Contudo, ela não foi vista em participação ativa no comércio ilícito. Após cerca de vinte minutos de observação, onde foram colhidas algumas imagens, a equipe policial optou pela abordagem. Os acusados foram abordados lado a lado, diante do bar (lado oposto da rua em relação ao estacionamento). Ao serem abordados, foi encontrado, em poder de Gustavo, uma porção de cocaína, escondida em seu boné, que este alegou ser para uso próprio. Em poder de Leonardo nada foi encontrado. Aos policiais, Leonardo confessou que apenas guardou a bolsinha com drogas junto ao automóvel FIAT/UNO, a pedido de um suposto terceiro indivíduo, cujo nome não revelou, mas que em nenhum momento foi visto pelos agentes. Victória declarou que foi ver seu namorado, Leonardo, após ter feito uma entrevista de emprego, afirmando não ter relação alguma com o tráfico apurado. A droga e o dinheiro eram mantidos na pochete que se escondia no veículo. Ao verificarem sua roda, foi achada a pochete sobre o pneu, contendo porções de cocaína, crack, maconha, frascos aparentando conter lança-perfume, uma folha de anotações aparentemente relativas ao tráfico, além da quantia de R\$ 57,00 em cédulas diversas. Foi dada voz de prisão para os acusados que alegaram apenas se conhecerem do bar, sendo ratificada pela Autoridade Policial. Victória foi ouvida e liberada visto ter sido apenas vista em companhia de Leonardo e não realizando qualquer conduta de traficância. Na sede, compareceu Dr. Leonardo, advogado, representando o acusado Gustavo.

Em juízo, disse que presenciou uma cena de tráfico de drogas em via pública. Os acusados atendiam os usuários que ali compareciam. Disse que eles ficavam ora na calçada, ora em frente ao estacionamento do conjunto habitacional. Disse que quando o usuário chegava, os réus pegavam o entorpecente em um veículo que estava estacionado. Que realizaram diversas imagens acerca da movimentação. Ambos foram abordados, sendo que Gustavo trazia em seu boné uma porção de cocaína. Na pochete que estava na roda do automóvel, localizaram 30 porções de cocaína, crack, 03 frascos de lança perfume, bem como dinheiro. Os acusados foram presos e conduzidos à unidade policial. Que a namorada de um dos réus estava no local, mas não participou da venda. Leonardo confessou o crime e atribuiu a propriedade da droga a um terceiro. Gustavo negou o crime.

A testemunha Aprigio Carlos da Silva Neto, policial civil, em sede administrativa, narrou os fatos em consonância e concordância com os informados por seu colega. Em juízo, disse que estava com seu colega em ponto de tráfico de drogas. Em dado momento, observaram dois indivíduos do lado oposto ao estacionamento do conjunto habitacional. Algumas pessoas chegavam, os acusados atravessavam a rua, pegavam algo no carro e depois voltavam. Ficaram cerca de 20 minutos tentando registrar os fatos. Em dado momento, optaram pela abordagem. Com Leonardo nada foi encontrado, ao passo que Gustavo trazia no boné uma porção de cocaína. Dentro de uma pochete localizada em um veículo, encontraram maconha, crack, cocaína, lança perfume e quantia em dinheiro. Leonardo admitiu a traficância. Disse que a namorada de Leonardo estava no local.

O réu Gustavo Pereira de Souza, em sede administrativa, afirmou que é usuário de cocaína e que a porção encontrada em seu poder era destinada a seu uso apenas. Explicou que não estava traficando e que conhece o acusado Leonardo apenas de vista

do bairro. Quanto aos fatos, narrou que, na data, encontrava-se em frente ao bar do CDHU e, por isso, foi abordado junto com Leonardo, quem estava no mesmo local, mas que nada sabia sobre a droga apreendida.

Em juízo, negou o crime. Disse que no dia dos fatos saiu de sua casa e foi para uma adega em frente à biqueira para usar drogas. Disse que entrou diversas vezes na biqueira para comprar e depois usar drogas. Que Leonardo também frequenta o local. O réu Leonardo Palma Nogueira, em sede administrativa, afirmou que não possuía advogado no momento, que não mora com seus familiares, mas sim com Victória desde janeiro de 2021. Quanto aos fatos, explicou que é usuário de cocaína e, na data, encontrava-se na frente do bar que fica do outro lado do estacionamento do CDHU. Nesse momento, foi abordado pelos policiais civis. Declarou que conhece Gustavo apenas do bar, visto que se mudou para o bairro apenas há seis meses. Quanto ao tráfico, declarou que um indivíduo quem desconhece pedira para que fosse esconder uma bolsinha em um veículo localizado dentro do estacionamento do CDHU. Assim o fez, deixando-a no escapamento de um veículo FIAT/Uno. Afirmou que sabia que havia droga na bolsinha mas nega ter vendido a droga para algum usuário, tendo, apenas, guardado-a. Quanto a sua namorada, Victória, explicou que ela foi apenas comer uma marmita em sua companhia após ter feito uma entrevista de emprego, declarando que ela não tem relação alguma com o tráfico.

Em juízo, negou o crime. Aduziu ser usuário de drogas. Que foi ao local dos fatos para comprar drogas. Que encontrou um rapaz que lhe ofereceu 03 pinos de drogas, sendo que em troca deveria guardar uma bolsa.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficou devidamente caracterizado o delito imputado aos réus, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

O conjunto probatório permite inferir que os acusados, previamente conluiados e agindo com unidade de desígnios, cada um fazendo sua a ação alheia, traziam consigo e tinham em depósito, com intuito de entrega a consumo de terceiros, 45ml (quarenta e cinco mililitros) de Cloreto de Metileno/Diclorometano, popularmente conhecido como lança-perfume, divididos em 03 (três) frascos, 115,5g (cento e quinze gramas e cinco decigramas) de Tetrahydrocannabinol (THC), acondicionados em 18 (dezoito) porções individuais, 3,0g (três gramas) de cocaína, na forma de crack, divididos em 20 (vinte) porções individuais, 12,7g (doze gramas e sete decigramas) de cocaína, divididos em 33 (trinta e três) porções individuais, 0,4g (quatro decigramas) de cocaína, acondicionados em 01 (uma) porção individual, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Importante salientar que a conduta dos acusados se amolda perfeitamente ao tipo penal supracitado.

Para caracterizar o delito, basta que um dos verbos descritos no tipo se concretize, não sendo necessário que o infrator seja surpreendido no ato de mercancia, visto que se trata de crime de perigo abstrato.

Oportunamente, cumpre destacar que os policiais civis reconheceram os réus como sendo os autores do delito.

Ouvidos sob o crivo do contraditório foram uníssomos, coerentes e convincentes, descrevendo em harmonia e com riqueza de detalhes toda a abordagem que culminou na prisão dos réus e na apreensão de todo o material. Destarte, inexistente qualquer motivo que leve esta magistrada a crer que as narrativas foram fantasiosas ou inverídicas.

Imprescindível salientar que os depoimentos dos policiais não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são agentes da segurança pública, pois "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes". (RT 411/266) Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita". (STF, RTJ 68/54)

São eles agentes do Estado, incumbidos a reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimentos coerentes e seguros, inexistindo qualquer motivo para levar a crer que

as narrativas foram inverídicas, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório.

Ademais, é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos dos agentes públicos de segurança não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Ademais, os acusados não apresentaram qualquer versão que pudesse fragilizar os elementos amealhados da instrução criminal, ou eximi-los de suas responsabilidades. Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

Ademais, o modo do acondicionamento da droga apreendida caracteriza de igual forma, a prática da mercancia, visto que as porções estavam prontas para serem distribuídas para comercializar.

As substâncias entorpecentes descritas na exordial acusatória foram confirmadas pelo laudo pericial preliminar e definitivo, atestando seus efeitos e sua periculosidade, sendo detectado, de fato, a existência de maconha, cocaína e Cloreto de Metileno/Diclorometano.

Outrossim, as circunstâncias do delito, tendo em vista que os acusados foram visualizados em atitude típica de mercancia, impede a desclassificação para o delito de porte de drogas para o uso pessoal. Inclusive, ao contrário do que aponta a defesa, há que se ressaltar que as fotos contidas no relatório de investigação encartado aos autos às págs. 51/70, demonstram que os acusados negociavam as drogas e as entregavam aos compradores, o que corrobora a versão apresentada pelos policiais.

Os registros fotográficos são suficientes para demonstrar a atividade típica de mercancia, com efetiva distribuição de atividades entre os réus. Não obstante as dificuldades dos policiais, esses registros ainda foram possíveis e corroboram o quanto relatado pelos policiais.

Importante destacar que ainda que as drogas não estivessem nas mãos do réu, mas sim no veículo, tal fato não afasta a participação do réu na traficância, ao contrário, os réus permaneceram a todo tempo nas proximidades do carro, possuindo e manejando as drogas que estavam ali guardadas.

Vale destacar que a versão do réu Gustavo de que ganharia três pinos para colocar a bolsa de drogas no local, não se reveste de qualquer razoabilidade, na medida que a pessoa por ele mencionada estava no próprio local onde estava sendo realizada a venda, não havendo, portanto, mínima lógica no que foi por si alegado.

É certo que, se é fato que o tráfico de drogas ilícitas banalizou-se, a ponto de propiciar a qualquer pessoa, mesmo que de renda mensal mínima a possibilidade de ganhar dinheiro com o tráfico, não é em razão disso que a conduta típica e antijurídica venha a ser menos perniciosa para a sociedade, posto que, como é cediço, o crime de tráfico, cujo bem jurídico é a saúde pública, dá causa, inegavelmente, a inúmeros outros ilícitos penais que são perpetrados em razão das drogas ou para propiciar a aquisição delas.

Data vênua às combativas defesas, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Para o acusado GUSTAVO PEREIRA DE SOUZA:

Na primeira fase da dosimetria, atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por inexistirem circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Na segunda fase, observada a agravante da reincidência (proc. 0035392-77.2005.8.26.0114 - pág. 78/79), majoro a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Não há atenuantes a serem observadas.

Na terceira fase, deixo de conceder o benefício ante a reincidência do acusado. Ressalto que passo a reconhecer a reincidência e a exclusão do benefício contido no artigo 33, parágrafo 4º da Lei, em consonância com reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, ainda que decorrente de apenas uma condenação transitada em julgado, pode ser utilizada para agravar a pena e, concomitantemente, para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sem se falar em bis in idem. Precedentes. 5. Estabelecida a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, o regime inicial fechado (mais grave segundo o quantum da sanção aplicada) é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista a reincidência do paciente, consoante as diretrizes do art. 33, § 2º, "a", do CP. Precedentes. (HC 391152 / SP, HABEAS CORPUS 2017/0049230-0)

Para o acusado LEONARDO PALMA NOGUEIRA:

Na primeira fase da dosimetria, atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por inexistirem circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Na segunda fase, não há elementos a serem observados.

Na terceira fase, para a redução da pena, é necessário que o réu seja primário, tenha bons antecedentes, comprove que não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Contudo, o §4º do artigo 33, tem sua referência justamente no caráter isolado da conduta realizada, pressupondo mesmo não disponha o réu no seu passado sinais de indicativos de que esteja fazendo do crime um meio de vida, atuando com profissionalismo.

Deve o julgador, neste caso, sopesar a quantidade de droga, variedades destas, bem como a análise do impulso, do fator determinante da conduta objetivamente tratada, que lhe permita concluir tratar-se mesmo de caso de um criminoso meramente ocasional, para que possa, não apenas determinar a gradação da redução da pena, como até mesmo o total afastamento da causa de redução.

Em relação ao réu, considerando os novos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência e o quanto determinado pelo STJ, de rigor reconhecer que as condições fáticas não permitem concluir que ele se dedique profissionalmente ao tráfico; além disso, a quantidade e variedade não é expressiva de modo a inviabilizar o benefício em questão. Assim, sendo o caso de aplicação do benefício no percentual de 1/2 (metade), resultando a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Sobre a possibilidade de utilizar a quantidade e diversidade de drogas como critério para diminuição da pena já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ARTIGO 33, PARÁGRAFO 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. ORDEM DENEGADA. 1. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida em poder da paciente justificam a aplicação do benefício previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, no piso mínimo (um sexto). 2. As instâncias inferiores decidiram em consonância com a jurisprudência desta e. Corte Superior, não caracterizada a coação ilegal descrita na inicial. 3. Ordem denegada. (STJ, HC 150407)

Por sua vez, oportuno ressaltar que não é inconstitucional a referida sanção pecuniária, a dar azo à aplicação desta pena nos termos do artigo 49 do Código Penal. Se o legislador optou por punir mais rigorosamente o crime de tráfico de drogas, em virtude de suas consequências nefastas à sociedade, justamente para desestimular a escolha desta atividade como meio de subsistência ou de enriquecimento - o que não viola qualquer princípio constitucional - cabe ao julgador aplicar a sanção pecuniária dentro dos limites legalmente estabelecidos, sendo certo que, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/06, o valor de cada dia-multa deve ser atribuído de acordo com a capacidade econômica do agente.

Nesse sentido: APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de desclassificação da conduta para a do artigo 28 da Lei de Drogas - Redutor de pena já beneficentemente aplicado, em fração intermediária - Penas e regime prisional

fixados com critério - Manutenção da pena de multa imposta, afastada a alegação de inconstitucionalidade - Negado provimento ao recurso. (TJ/SP - Apelação n.º 0014590-34.2014.8.26.0602/ SP, Rel. Des. Ricardo Sale Júnior, julgado em 30/07/2015, 15ª Câmara de Direito Criminal, publicado em 02/08/2015).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR os acusados:

- 1)- GUSTAVO PEREIRA DE SOUZA ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
- 2)- LEONARDO PALMA NOGUEIRA ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. O dia-multa valerá o mínimo legal.

Determino o regime fechado para início do cumprimento da pena do acusado Gustavo, pelo quantum de pena aplicado, gravidade do delito cometido, bem como pela sua reincidência, sendo inviável, portanto, a aplicação de regime mais brando.

Para o réu Leonardo, determino regime semiaberto para início do cumprimento de pena, adotando como posicionamento a fundamentação exarada no V.Acórdão

2018.000245841, sendo relator o sempre culto Desembargador Nelson Fonseca Júnior;"... a teor a despeito da extensão das penas corporais aplicadas, não é caso de se manter o regime inicial aberto; quer em razão da gravidade do delito e da natureza de um dos entorpecentes apreendidos, quer em razão de o regime inicial aberto não se mostrar suficiente à prevenção e à repressão da infração penal perpetrada pelo réu (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal), além de não garantir o cumprimento das penas substitutivas impostas."

O réu Leonardo poderá recorrer em liberdade, eis que permaneceu solto durante a instrução do processo.

Substituo a pena privativa de liberdade imposta a Leonardo por duas restritivas de direitos, uma consistente na prestação de serviços à comunidade e outra à frequência a curso ou tratamento, ambas pelo período de cumprimento de pena e em locais a serem indicados pelo Juízo da Execução.

O réu Gustavo não poderá recorrer em liberdade, visto que permaneceu preso durante a instrução, inexistindo alteração fática nos motivos que determinaram o decreto da prisão preventiva. Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito, afirmando: "A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal". (RHC nº 23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008).

Destaco que o réu é reincidente e voltou a delinquir, de sorte que, a persistência na prática delitiva mostra que, em liberdade, retornará a praticar novos delitos, o que revela a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos para Gustavo, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução Criminal e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: "Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva Inadmissibilidade Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório Penas mantidas Regime escorreitamente fixado Impossibilidade de detração - A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido." (Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial. Destaco que o montante da pena cumprida provisoriamente é insuficiente para alterar o regime inicial, sendo determinante para a fixação do regime, neste caso, a gravidade do delito, bem como pela sua reincidência.

Declaro o perdimento dos valores apreendidos em favor da União.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA